

# Helmut Frister

---

*Derecho Penal. Parte General — Traducción de la 4.<sup>a</sup> edición alemana (2009), Editorial Hammurabi, 2011*

**Línea teórica:** Teoría funcional-normativa de la imputación con énfasis en la capacidad de auto-determinación como concepto normativo (no psicológico). Proximidad a concepciones de Roxin sobre imputación objetiva y teoría del dominio del hecho.

## Tesis central

---

La culpabilidad se fundamenta en la capacidad de auto-determinación del agente, entendida no como hecho psicológico sino como construcción social y normativa. El Derecho penal sólo puede imponer pena sobre conductas auto-determinadas que lesionen materialmente bienes jurídicos, respetando los límites del principio de legalidad. La imputación del resultado al sujeto requiere concurrencia de causalidad, imputación objetiva (riesgo jurídicamente reprobado) y dolo o imprudencia.

## Panorama

---

Manual sistemático que expone la Parte General del Derecho Penal alemán de forma ilustrativa y coherente, resolviendo problemas similares sin contradicciones valorativas. Eje central: la teoría general del delito bajo el principio de culpabilidad entendido como postulado normativo de auto-determinación. Abarca fundamentos (pena, culpabilidad, legalidad), estructura del delito (acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad), formas especiales (omisión, tentativa, autoría y participación) y consecuencias jurídicas.

## Postura en la teoría del delito

---

### Acción

La acción es el fundamento del análisis de la tipicidad. Frister concibe la acción como conducta causante de un resultado o como omisión de impedir un resultado cuando existe obligación de garante. La acción presupone movimiento corporal conducible por la voluntad, distinto de sucesos de la naturaleza. Nexo causal entre conducta y resultado es necesario pero insuficiente: requiere además imputación objetiva.

### Tipicidad objetiva

Estructura compuesta por: (1) conducta típica (acción u omisión), (2) resultado típico (en delitos de resultado), (3) elementos del tipo objetivo (circunstancias, cualidades). La tipicidad objetiva es condición de la tipicidad en su conjunto; su ausencia excluye tipicidad subjetiva. Los elementos del tipo pueden ser descriptivos (perceptibles empíricamente) o normativos (requieren valoración jurídica).

### Imputación objetiva

Teoría del riesgo permitido: un resultado es objetivamente imputable cuando (1) el comportamiento crea un riesgo jurídicamente relevante, (2) no es permitido por el ordenamiento (riesgos permitidos se excluyen), (3) se realiza el riesgo en el resultado concreto, no mediante despliegue causal hipotético. Crítico: fin de protección de la norma de deber; acciones de terceros y del lesionado pueden interrumpir la imputación objetiva si son autónomas o si el deber no las abarcaba. Realización del riesgo reprobado es determinante.

## **Tipo subjetivo · Dolo**

Dolo como decisión consciente en favor del acontecer típico. Frister rechaza elemento volitivo adicional (no requiere 'querer'); basta la representación. Dolo contiene: (a) conocimiento de los elementos fácticos del tipo, (b) conciencia de la realización (no basta representación calificada de posibilidad: debe haber representación de realización). Clases: dolo directo (intención inmediata), dolo directo de segundo grado (aceptación consciente), dolo eventual (representación de posibilidad con indiferencia—pero NO mero dolo eventual de imprudencia consciente). En imprudencia: no hay dolo, sino incumplimiento del deber de cuidado conocible.

## **Error de tipo**

Error sobre elementos fácticos del tipo excluye el dolo (error de tipo esencial). Si es evitable, subsiste delito imprudente si el hecho es punible a título de imprudencia. Error ineversible excluye responsabilidad penal. No hay error de tipo cuando el autor ignora elementos normativos (para estos rige regla especial). Error sobre causalidad es error de tipo si afecta representación de realización.

## **Antijuridicidad**

Juicio de valor sobre la acción típica: declara que el hecho viola el ordenamiento jurídico. La antijuridicidad es divisible: un mismo hecho puede ser típico pero justificado (p. ej., legítima defensa). Estructura de causas de justificación: (1) tipo permisivo objetivo (situación de hecho justificante: agresión, peligro, consentimiento), (2) tipo permisivo subjetivo (conocimiento de requisitos). Frister adopta estructura cerrada de justificaciones: consentimiento, legítima defensa, estado de necesidad justificante, derechos de función pública. Cumplimiento del deber es causa de justificación.

## **Culpabilidad**

Reproche personal basado en capacidad de auto-determinación. Presupuestos: (1) imputabilidad (capacidad de comprensión y conducción conforme a derecho; §§ 19-21 StGB), (2) conciencia de ilicitud (posibilidad de comprender que el hecho es antijurídico; § 17 StGB), (3) exigibilidad (ausencia de estado de necesidad exculpante; § 35 StGB). Frister subraya que auto-determinación es construcción normativa preconfigurada por la vida social, no dato psicológico. La culpabilidad es grado del reproche, no binario sino variable según intensidad de decisión y circunstancias.

## **Error de prohibición**

Error sobre la antijuridicidad del hecho (consciencia del ilícito). Si es inevitable, excluye culpabilidad. Si es evitable, modifica culpabilidad (§ 17 StGB): depende de si el autor pudo conocer, en la situación concreta, que el hecho era antijurídico. Criterio: capacidad de información técnica del sujeto (no equivale a conocimiento jurídico profesional). Error de prohibición en delito imprudente: requiere consciencia de violación de deber de cuidado.

## **Tentativa**

Punible desde el comienzo de ejecución (§ 22 StGB). Comienzo de ejecución requiere: (1) decisión al hecho (plan delictivo firme), (2) inmediatez (inicio de realización típica). Frister distingue entre tentativa acabada (todo ejecutado conforme al plan pero falta resultado) e inacabada. Tentativa inidónea es punible si el autor cree erróneamente en la idoneidad del medio; si sabe de la inidoneidad, subsiste tentativa (error sobre capacidad de ejecución no excusa). Desistimiento antes de comienzo de ejecución exime de pena por tentativa. Desistimiento en tentativa inacabada extingue punibilidad si es voluntario (§ 24 StGB). Tentativa acabada: punible aunque sea voluntario el abandono si logra impedir la consumación.

## Autoría y participación

Distinción entre autoría (dominio del hecho) y participación (accesoriedad). Autoría directa: quien realiza personalmente el tipo. Coautoría: comunidad del actuar (plan común vinculante, decisión común, necesidad de intervención). Autoría mediata: utilizar a otro como instrumento (dominio de la voluntad mediante coacción o error). Participación: complicidad (contribución a tipo ajeno) e instigación (determinación consciente a comisión del delito). Elemento personal especial: delitos que requieren cualidades especiales del autor (p. ej., funcionario) limita coautoría y requiere complicidad si participe no reúne cualidad.

## Posturas en debates clave

---

- **Dolo eventual vs. imprudencia consciente.** Frister rechaza elemento volitivo adicional en dolo (no requiere 'aceptación' más allá de representación). El dolo eventual se diferencia de imprudencia consciente por la representación del riesgo: en dolo hay conciencia de realización; en imprudencia consciente hay mera representación de posibilidad pero convicción de evitar el resultado. Criterio subjetivo: disposición interna del agente ante la representación del riesgo. (Capítulo 11 (El dolo de tipo), § 224 ss.)
- **Imputación objetiva y fin de protección de la norma.** La realización del riesgo debe darse dentro del ámbito de protección de la norma de deber. Acciones de terceros o del lesionado pueden romper la cadena de imputación si son autónomas o caen fuera del fin de la norma. No basta causalidad: requiere imputación normativa conforme al sentido de la norma violada. (Capítulo 10 (La imputación objetiva))
- **Culpabilidad como postulado normativo, no hecho psicológico.** La auto-determinación es construcción social y normativa (Luhmann), no capacidad psicológica real de poder-haber-actuado-de-otra-forma (libertad de voluntad kantiana). El Derecho penal se ancla en la vivencia social de reconocimiento mutuo de autonomía. Los parámetros de capacidad de auto-determinación son preconfigurados por la vida social pero concretos por la ley (p. ej., edad penal en § 19 StGB). (Capítulo 3 (El principio de culpabilidad), n. m. 9-13)
- **Tentativa inidónea.** Es punible si el autor cree erróneamente en la idoneidad del medio (error sobre medio). Si sabe de la inidoneidad (p. ej., intenta matar con agua), subsiste tentativa porque el dolo abarca la intención de realizar el tipo aunque el medio sea necesariamente ineficaz. La punibilidad no depende de oportunidad fáctica sino de decisión del agente. (Capítulo 23 (Tentativa y preparación))
- **Autoría mediata por dominio de la voluntad.** Autor mediato es quien domina la voluntad de un tercero mediante coacción (vis absoluta, coerción irresistible) o error (inducción de conducta típica sin consciencia). Coacción que elimina auto-determinación hace responsable al coactor, no al ejecutor. Diferente de instigación (determinación consciente a comisión). (Capítulo 25 (La estructura básica de las formas de intervención))
- **Desviación del curso causal e imputación al dolo.** Desviaciones respecto del curso causal representado no excluyen dolo si el resultado se produce en el bien jurídico abarcado por el dolo. Ejemplo: intenta matar A por envenenamiento, falla el veneno pero A muere atropellado; es imputable si el dolo abarcaba muerte de A. Aberratio ictus: si se daña a persona distinta de la prevista, hay dolo respecto de la víctima si bien jurídico es similar. (Capítulo 11, Sección IV (La imputación del resultado al dolo))
- **Posiciones de garante y delitos de omisión.** Obligación de impedir resultado surge de (1) dominio de la fuente del peligro (control de cosa), (2) conducta previa generadora de peligro, (3) asunción voluntaria de protección. No hay obligación de garante genérica por solidaridad, sino por vínculo jurídico específico. Garantes de control vs. de protección tienen regímenes distintos. (Capítulo 22 (El delito de omisión))
- **Capacidad de culpabilidad y actio libera in causa.** Imputabilidad requiere capacidad de comprensión (entender significado del deber) y conducción (poder actuar conforme a derecho). Actio libera in causa: quien se coloca a sí mismo en estado de incapacidad (ej. se emborracha antes de conducir) es punible por la acción anterior, no por la conducta posterior incapaz, porque en el acto de colocarse voluntariamente en ese estado sí tenía capacidad. (Capítulo 18 (La capacidad de culpabilidad))

## Glosario

---

- **Auto-determinación:** Capacidad normativa (no psicológica) de obrar conforme a la propia decisión, reconocida socialmente como autonomía. Base del principio de culpabilidad. Construcción social que estructura el mundo social distinto de la naturaleza.
- **Imputación objetiva:** Atribución normativa del resultado típico al comportamiento: requiere que el riesgo creado sea jurídicamente reprobado y se realice en el resultado concreto, dentro del fin de protección de la norma violada.
- **Riesgo permitido:** Riesgos que el ordenamiento jurídico tolera, cuya materialización no es imputable objetivamente. Ejemplo: circulación de automóviles crea riesgo permitido de accidente.
- **Fin de protección de la norma:** Ámbito que la norma de deber protege. La realización del riesgo fuera de este ámbito no es imputable. Determina si acciones de terceros o del lesionado interrumpen la imputación.
- **Dolo de tipo:** Conocimiento y conciencia de realización de los elementos fácticos del tipo. No requiere elemento volitivo adicional; basta representación consciente de que se realiza el tipo.
- **Dolo eventual:** Variante del dolo: representación de la posibilidad de realización del tipo con consciente indiferencia ante esa posibilidad. Se diferencia de imprudencia consciente en que la posibilidad es representada como efectiva, no sólo como potencial.
- **Error de prohibición:** Desconocimiento o error sobre el carácter antijurídico del hecho. Si es inevitable, excluye culpabilidad; si es evitable, sólo la disminuye (§ 17 StGB).
- **Garante:** Sujeto que por vínculo jurídico específico tiene obligación de impedir un resultado determinado. Categorías: garantes de control (dominio de cosa/fuente peligro) y garantes de protección (vínculos familiares, función pública).
- **Causalidad alternativa:** Hipótesis donde múltiples condiciones causan el mismo resultado, sin certeza de cuál fue determinante. Requisito: cada una de las condiciones debe ser condicio sine qua non del resultado.
- **Aberratio ictus:** Desviación del golpe: quien pretende dañar a persona A y por error daña a persona B. Es imputable si ambos son bien jurídico similar; si bien distinto, no hay consumación del dolo.

## Mapa de capítulos

---

### Capítulo 1: Objeto de regulación y fuentes del Derecho penal 29-57

Define pena como sanción pública represiva, la distingue de sanciones administrativas y medidas, expone el sistema de regulación (Derecho penal material, procesal, de minoridad) y panorama de Derecho penal europeo e internacional.

### Capítulo 2: El fin de la pena 59-72

Análisis de teorías tradicionales (absoluta, preventiva general y especial) y teoría de prevención general positiva. Frister adopta enfoque múltiple: la pena debe satisfacer simultáneamente justificación (responsabilidad), prevención y fin de reinserción.

### Capítulo 3: El principio de culpabilidad 73-87

Fundamento constitucional de la culpabilidad. Auto-determinación como postulado normativo. Requisito de ilícito material (concepto de bien jurídico). Principio in dubio pro reo.

### Capítulo 4: El principio de legalidad y la reserva judicial 89-111

Nullum crimen sine lege: principios de lex scripta, lex certa (determinación), lex stricta (prohibición de exceder), lex praevia (vigencia al momento del hecho). Límites de la determinación legal.

## **Capítulo 5: Ámbito de validez temporal y espacial de las leyes penales** 113-125

Aplicación de ley más benigna. Validez espacial: principios territorial, de bandera, de personalidad, de protección, universal. Concepto de lugar del hecho.

## **Capítulo 6: Consecuencias jurídico-penales** 127-146

Penas privativas de libertad, de multa, prohibición de conducir. Medidas de corrección y seguridad. Decomiso. Suspensión condicional.

## **Capítulo 7: Introducción a la teoría general del delito** 147-160

Objeto y función de la teoría del delito. Estructura del delito (elementos). Formas generales: comisión/omisión, dolo/imprudencia, consumación/tentativa, autoría/participación. Distinción entre crímenes y delitos.

## **Capítulo 8: La estructura del tipo** 161-176

Acción como fundamento del análisis de tipicidad. Distinción entre tipo objetivo y subjetivo. Elementos típicos descriptivos y normativos. Delitos de resultado y actividad.

## **Capítulo 9: La causalidad de la acción respecto del resultado** 177-198

Distinción entre causalidad e imputación objetiva. Condicio sine qua non vs. condición ajustada a ley. Causalidad alternativa. Cursos causales hipotéticos.

## **Capítulo 10: La imputación objetiva** 199-218

Concepto y presupuestos. Riesgo jurídicamente reprobado. Exclusión de riesgos irrelevantes. Riesgos permitidos. Valoración de riesgos con intervención de terceros o lesionado. Realización del riesgo.

## **Capítulo 11: El dolo de tipo** 219-248

Dolo como decisión consciente en favor del acontecer típico. Estructura psíquica: formas de dolo. Delimitación dolo eventual/imprudencia. Objeto del dolo. Imputación del resultado al dolo. Desviaciones causales, aberratio ictus.

## **Capítulo 12: La imprudencia** 249-262

Paralelismo con dolo. Imprudencia como conocibilidad. Presupuestos: conocimiento empírico, conocimiento de base de hecho, tiempo necesario. Formas: consciente e inconsciente. Imputación del resultado.

## **Capítulo 13: Panorama de las causas de justificación** 265-272

Clasificación de justificaciones por interés (afectado, otros/generalidad). Consentimiento, consentimiento presunto, patria potestad, derechos públicos, necesidad, legítima defensa, auto-auxilio.

## **Capítulo 14: Teoría general de la justificación** 273-300

Objeto y estructura de la justificación. Divisibilidad del juicio de antijuridicidad. Tipo permisivo objetivo y subjetivo. Error sobre la justificación. Justificación en delito imprudente.

## **Capítulo 15: [Acuerdo excluyente del tipo]** 301

Acuerdo que excluye tipicidad vs. consentimiento que justifica. Distinción operativa: consentimiento produce atipicidad en algunos delitos.

## **Capítulo 16: Consentimiento y consentimiento presunto** 302-318

Requisitos: capacidad de consentir, voluntariedad, contenido de decisión, no coacción. Derecho de disposición limitado. Consentimiento presunto para casos de imposibilidad de obtener.

## **Capítulo 16b: Legítima defensa y exceso** 319-342

Situación: agresión antijurídica y actual. Requisitos de acción defensiva: injerencia en bien del agresor, aptitud, proporcionalidad. Restricciones ético-sociales (agresiones inculpables, provocadas, comunidades estrechas). Exceso.

## **Capítulo 17: Estado de necesidad justificante** 343-362

Necesidad agresiva y defensiva. Peligro actual. Necesidad de acción. Preponderancia esencial de interés. Adecuación. Provocación y exceso.

## **Capítulo 18: Capacidad de culpabilidad** 363-378

Imputabilidad: capacidad de comprensión y conducción. Perturbaciones psíquicas (§§ 20-21 StGB). Actio libera in causa. Regulación de capacidad de culpabilidad.

## **Capítulo 19: Posibilidad de comprender el ilícito** 379-386

Consciencia del ilícito (error de prohibición). Objeto de consciencia. Divisibilidad. Evitabilidad. Conducta de funcionarios.

## **Capítulo 20: La exigibilidad** 387-405

Estado de necesidad exculpante (§ 35 StGB). Peligro para vida, cuerpo, libertad. Deberes espaciales de soportar peligro. Otras causas de exculpación.

## **Capítulo 21: Otros presupuestos de la punibilidad** 406-425

Causas de exclusión de pena. Condiciones de punibilidad. Persecución dependiente de voluntad del lesionado. Prescripción. Descarte del ilícito insignificante.

## **Capítulo 22: El delito de omisión** 426-460

Regulación § 13 StGB. Delimitación comisión/omisión. Obligación de impedir resultado: garantes de control y de protección. Tipo subjetivo. Justificación y culpabilidad de omisión.

## **Capítulo 23: Tentativa y preparación** 463-489

Fundamento punitivo. Requisitos: decisión al hecho (plan firme), comienzo de ejecución (inmediatez). Tentativa inidónea. Preparación.

## **Capítulo 24: Desistimiento de la tentativa** 493-530

Fundamentos de impunidad. Desistimiento en tentativa inacabada (abandono voluntario). Desistimiento en tentativa acabada (esfuerzo serio por impedir consumación).

## **Capítulo 25: Estructura básica de las formas de intervención** 531-555

Panorama de autoría, coautoría, autoría mediata y participación. Estructura y presupuestos de cada forma. Elementos personales especiales.

## **Capítulo 26: La coautoría** 557-572

Comunidad del actuar: plan vinculante, acción unitaria, exclusión de excesos, coautoría sucesiva. Medida de intervención: teoría subjetiva vs. dominio del hecho.